

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

[기출][2024-1-1-1]거부처분에 대하여 대한민국을 피고로 지정한 민사상 금전지급 청구소송의 적법 여부 및 법원의 판단

《[문제1] 甲은 X주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y지방고용노동청 Z지청장(이하 'A'라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024. 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제70조 제2항에서 정한 '육아휴직이 끝난 날 이후 12개월'이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제15조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50점)

(물음1) 아래의 각 경우 법원의 판단에 관하여 설명하시오. (30점)

(1) 甲은 「고용보험법 시행령」 제94조 제3호에 해당하는 사유(직계비속의 질병)가 끝난 후 30일 이내 신청하였으므로 육아휴직급여 청구권이 있다고 주장하면서, 2024. 8. 1. 대한민국을 피고로 하여 금전의 지급을 구하는 민사소송의 소장을 서울지방법원에 제출하여 접수되었다. 국가소송수행자 B는 소송이 적법하지 않으므로 각하판결이 내려져야 한다고 항변한다. (15점)

- 지방공무원법 제20조의2 [행정소송과의 관계]
- 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 [시간외근무수당]
- 고용보험법 시행규칙 제105조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제119조 [육아휴직등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

<문제1의 물음1-1> 거부처분에 대하여 대한민국을 피고로 지정한 민사상 금전지급 청구소송의 적법 여부 및 법원의 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 육아휴직급여 청구권이 있음을 주장하며 대한민국을 상대로 금전 지급을 구하는 민사소송을 제기하였고, 국가소송수행자는 해당 소송이 부적법하다고 항변하는 상황이다. 쟁점으로 <육아휴직급여 지급청구와 같이 행정청의 처분을 전제로 하는 공법상 금전청구를 어떠한 소송 형태로 제기하여야 하는지와 민사소송의 적법 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 국가소송수행자 B의 각하판결이 내려져야 한다는 항변에 대한 법원의 판단에 대해 설명한다.

II. 육아휴직급여 청구권의 성질과 구제소송의 요건

1. 육아휴직급여 청구권의 법적 성질과 처분의 선행 필요성

(1) 공법상 수급권의 성질

- 고용보험법에 따른 육아휴직급여는 국가가 헌법상 사회보장수급권의 이념을 실현하기 위하여 법령이 정한 요건을 갖춘 자에게 지급하는 공법상의 급여 청구권이다.

(2) 구체적 권리 발생의 시기 (판례의 태도)

- "대법원"은 고용보험법상의 육아휴직급여 청구권은 법령의 요건을 충족하는 것만으로 당연히 발생하는 권리가 아니라고 판단한다. 당사자의 신청에 대하여 관할 직업안전기관의 장이 급여를 지급하겠다는 구체적인 지급결정 처분을 내림으로써 비로소 구체적인 권리가 확정·발생한다. 따라서 행정청의 적법한 지급결정이 존재하지 않는 한, 직접 국가에 대하여 구체적인 급여의 지급을 청구하는 것은 실체법상 허용되지 않는다.

2. 거부처분에 대한 불복소송의 유형과 민사소송의 한계

(1) 거부처분 취소소송의 제기 의무

- 행정청이 육아휴직급여 지급을 거부한 행위는 신청인의 법적 지위에 직접 불이익을 초래하는 공권력의 행사 또는 그 거부로서 "행정소송법 제2조 제1항 제1호"의 처분에 해당한다. 따라서 이에 불복하여 권리를 획득하고자 하는 자는 관할 고용노동청 지청장을 피고로 삼아 거부처분 취소소송이라는 항고소송을 제기하여 거부처분의 위법성을 적극적으로 제거하여야 한다.

(2) 직접적인 민사소송 제기의 위법성

- 행정청의 거부처분이라는 선행 처분이 엄연히 존재함에도 불구하고, 이를 거부처분 취소소송을 통해 해결하지 아니한 채 직접 대한민국을 상대로 민사상 금전지급 청구소송을 제기하는 것은 소송물의 선택 및 소송 형태를 완전히 그르친 것으로서 소의 이익을 결여하여 매우 부적법하다.

3. 소송 유형의 잘못과 피고오지정에 대한 법원의 조치

(1) 행정소송법 제21조에 따른 소 변경의 유도

- 민사소송이 제기된 수소법원은 단순히 소송 형태가 잘못되었다는 이유로 즉시 각하해서는 안 된다. 실질적인 분쟁의 실체가 거부처분 취소소송에 해당한다면, 법원은 적극적으로 석명권을 행사하여 피고를 처분 행정청으로 경정("제14조")하고, 소송 유형을 거부처분 취소소송으로 변경("제21조")하도록 유도하여야 한다.

(2) 관할 행정법원으로서의 사건 이송

- 법원은 소 변경 절차와 함께 사건에 대한 관할권을 지닌 관할 행정법원으로 사건을 이송("행정소송법 제7조")함으로써 국민의 재판청구권을 보장하고 권리구제의 실효성을 높여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 소송 제기 방식의 위법성

(1) 소송 유형 및 청구의 부적법

- 甲이 구하는 육아휴직급여 청구권은 피고 A의 구체적인 지급결정 처분이 있어야 비로소 확정되는 공법상 권리이다. 따라서 甲은 거부처분 취소소송을 통해 구제를 도모해야 함에도 처분의 위법성을 거치지 않은 채 국가를 상대로 민사상 금전지급을 직접 청구하였으므로, 이는 소송의 형태를 오인한 것으로서 소의 이익을 결여하였다.

(2) 피고 지정 및 관할의 오류

- 항고소송의 피고는 처분을 행한 행정청인 Y지방고용노동청 Z지청장(A)이 되어야 한다. 그러나 甲은 권리의 의무의 귀속주체인 대한민국을 피고로 잘못 삼아 민사법원에 소를 제기하였으므로 피고적격과 관할권의 중대한 흠결이 존재한다.

2. 국가소송수행자 B의 항변과 수소법원의 최종 조치

(1) B의 각하 항변의 정당성

- 이 사건 소송은 구체적 급여 청구권이 발생하기 전에 제기된 직접적인 금전청구로서 소의 이익이 없으며 피고적격도 결여하였다. 따라서 적법하지 않은 소로서 각하되어야 한다는 국가소송수행자 B의 항변은 법리적으로 전적으로 타당하다.

(2) 법원의 구체적 심리 방향과 판단 형태

- 민사법원인 수소법원은 즉시 각하 판결을 선고할 것이 아니라, 구체적인 석명권을 발동하여 甲에게 피고를 Y지방고용노동청 Z지청장(A)로 경정하고 청구취지를 거부처분의 취소로 변경하도록 촉구해야 한다. 만약 甲이 법원의 석명에 응하여 소 변경을 신청하는 경우, 법원은 이를 허가하고 관할 행정법원으로 사건을 이송하는 결정을 내려야 한다. 그러나 법원의 유도와 석명에도 불구하고 甲이 민사소송 형태와 대한민국에 대한 금전청구를 끝내 고집한다면, 법원은 소송요건 흠결을 이유로 소 각하 판결을 선고하여야 한다.

IV. 결론

- 고용보험법상 육아휴직급여 청구권은 처분을 통하여 비로소 권리가 확정되므로 거부처분 취소소송을 제기하여야 한다. 이를 무시하고 직접 대한민국을 상대로 제기한 민사상 금전지급 청구소송은 부적법하므로 각하를 구하는 국가소송수행자 B의 항변은 타당하다. 결론적으로 수소법원은 석명권을 통하여 항고소송으로의 소 변경 및 피고경정을 유도한 후 관할 행정법원으로 사건을 이송하는 조치를 취해야 하며, 만약 원고 甲이 소 변경을 거부하는 경우에는 최종적으로 소 각하 판결을 내려야 한다.